

创设 WDO: 数字贸易全球治理的中国方案

杨 东, 乐 乐

摘 要: 当代以国际法为基础的国际秩序建构于二战后由联合国、WTO 等国际组织规则体制运行的一整套国际法律规范之上。随着人类社会由工业文明进入数字文明,“生产大爆炸”激发“交易大爆炸”,数据作为生产要素驱动新质生产力发展,原有的国际规则体系无法满足基于“平台、数据、算法”的新型法律关系的规则需求,这一问题在经贸领域尤为突出。在数字经济时代,数据跨境交易、生成式人工智能跨境服务贸易等数字贸易新形态应运而生,WTO 框架下传统的货物贸易、服务贸易规则无法直接适用于这一新兴领域,因而产生新的规则需求。然而,由于基础国际数字规则的缺失,WTO 数字贸易议题谈判及 WTO 自身改革因各成员方无法达成共识长期陷入僵局。在此背景下,美国绕开 WTO,通过区域贸易协定构建排斥中国的数字贸易生态圈,进一步加剧了数字贸易规则的碎片化。所以,单靠传统国际组织多边体制无法完全满足新的国际法律关系的需求。基于此,本文提出由中国主导创设世界数据组织(WDO)专注于数字国际规则的构建这一创新性的尝试,为经贸等专门领域的全球治理提供基础制度支撑,为构建公正的世界秩序贡献中国方案。当然,传统法律关系并未消亡,WDO 与传统国际组织体制下的规则协调同样重要。

关键词: 数字贸易; 人工智能; 中国方案; WTO; WDO(世界数据组织)

中图分类号: D990 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-462X(2025)01-0087-12

DOI: 10.20231/j.cnki.xxyts.2025.01.010

一、问题的提出

随着数字经济的壮大,一国制造、出口全球向全球制造、全球销售演进,数字贸易^①蓬勃兴起,数字贸易不仅涵盖以货物贸易的下单、物流、报关、支付等为环节的数字化转型和服务贸易中跨境电商、音视频产品等内容服务,还包括大型数字平台支撑的跨境开户、机票酒店预订、签证办理、考试服务、办公软件跨境提供服务等数字技术服

务,甚至包括人工智能、机器学习等技术跨境提供服务、数据产品跨境交易等新型贸易形式,形成了全新的国际贸易形态。

目前,传统国际贸易组织 WTO 框架下的数字贸易议题谈判长期陷入僵局,无法对数字贸易进行有效规制。部分国家通过 USMCA, CPTPP 等区域贸易协定(Regional Trade Agreements,以下简称 RTAs)或自由贸易协定(Free Trade Agreements,以下简称 FTAs)规则构筑的特定成员范围的数字贸易“小院高墙”蓬勃发展,造成了数字贸易规则的碎片化。从目前的实践来看,一方面,基于不同的价值取向,各个区域贸易协定间的安排存在较大的差异^[1]。例如,出于保持数字贸易领先地位的需要,由美国主导的区域贸易协定重点关注数字产品的非歧视待遇、保障数据自由流动、禁止数据本地化等问题;出于保护人权和尊重隐私的需要,由欧盟主导的区域贸易协定则格外强调数字贸易过程中的消费者权益保护和个人隐私

^① 根据中华人民共和国商务部《中国数字贸易发展报告(2024)》,数字贸易是一种以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的贸易新形态。

基金项目: 国家社会科学基金重点项目“数据要素收益分配法律问题研究”(24AZD021)。

作者简介: 杨东,浙江工商大学法学院特聘教授,中国人民大学涉外法治研究院教授; 乐乐,浙江工商大学法学院博士研究生。

保护。另一方面,在 WTO 数字贸易规则长期陷入谈判僵局的背景下,美国等国积极主导的区域贸易规则的谈判事实上体现了其争夺数字贸易规则制定主导权的“野心”,具有单边主义色彩^[9],减损了 WTO 的权利义务^[10]。而这些争夺主导权的企图之间必然是互不兼容的,这也在一定程度上凸显了区域贸易协定之间的“意大利面碗”^[11]现象,形成了数字贸易规则条块分布、美国一家独大的现实格局。这一方面导致数字鸿沟影响下的发展中国家缺乏数字贸易国际规则谈判的议价能力,无法参与到数字红利的全球共享中来;另一方面,数字贸易国际规则的碎片化导致我国的出海数字平台企业面临极为苛刻的全球运营条件,提高了其在各国合规运营的成本,不利于其全球竞争力的提升。

因此,当前亟待解决的问题是厘清 WTO 框架下数字贸易规则“难产”导致规制乏力的根本原因,分析建立世界数据组织(World Data Organisation,以下简称 WDO)的现实性和可行性,为数字贸易规则谈判贡献“中国方案”,也为我国加强涉外法治建设,增强数字国际规则话语权提供理论支撑,维护中国数字平台企业通过科技创新公平参与国际竞争的权益。

一、WTO 改革突破数字贸易谈判僵局的局限性

(一) 数字经济时代新型国际法律关系的产生

在数字经济时代,数据要素的生产要素作用得到凸显,大数据、云计算、人工智能等颠覆式创新技术集群的高速发展将人类活动的时空维度进行了极大的拓展,人类正在进入一个“数据地球”^[12]时代,国际贸易模式已经由 20 世纪传统贸易过渡到 21 世纪价值链贸易^[13],从强调专业分工到强调数据要素一体化协同及利益共创。

数字贸易的生产在很大程度上依赖移动、存储和使用数据。无形的数据成为新的价值载体、生产要素和国际贸易的命脉^[14]。数据通过流动实现价值创造。数据具有非排他性、共享和非稀缺性^[15],数据要素可以在不同主体不同用途的使

用链条中实现价值的指数级增长而不是消耗,数据要素利用的价值网络越大、生态越丰富,价值递增越明显。这就决定了土地、石油、劳动力、技术、资本等工业经济时代的生产要素,其价值实现的重心在于效率提升、成本降低、组织更优和更加公平的利益分配^[16]。数据在其流通过程中基于算法、模型、平台的聚合,与技术、资本、劳动和土地等生产要素相结合创造价值,实现从信息要素到生产要素的转变^[17]。一个主体对于特定数据要素的使用并不妨碍另外一个主体同时对其利用,数据的形成和收集成本可能较高,但数据的复制和迁移成本一般而言较低,整合和分割数据亦较为容易^[18]。数据取代有形货物成为数字经济时代新的国际法律客体。

在数字贸易中,新的商业模式由数据驱动,依托大数据、人工智能、云计算、区块链等技术的算法进行交易定价或消费者偏好预测,甚至 ChatGPT 等生成式人工智能技术已经能够处理更加复杂的运算和数据处理任务。自动处理包括复杂运算和数据处理的重复任务。在传统货物贸易中,实物商品一般都需要通过位于各国的线下门店进行展示与推广,因此,企业从各国获取的流量往往受到各国间经贸政策及各国监管的限制。但在数字时代,跨国科技企业在提供信息服务时无须进行商品的实体展示,仅依靠用户的 APP 在数字平台上注册账号并在算法的支撑下就实现了网络空间中的商品推广,用户的每一次“点击”都会为平台引入流量,随后转化为平台在市场竞争中的竞争优势。尽管从表面来看,平台的用户各自独立,并未与这些数字平台产生直接的数据交易,但实际上,数字平台已经利用算法支撑的电子支付等渠道,获取了用户的个人隐私数据、金融数据等有价值的信息,对这些数据进行分析、利用,转化为经济价值^[19]。基于此,算法成为使数据发挥更大经济价值的新型法律行为。

在数字经济时代,流量入口之于国际贸易,就如同农业经济时代水源之于土地灌溉,工业经济时代石油开采之于经济发展。平台汇集巨大的用户数量后,对其作为流量入口汇集的海量数据资源进行调控与分配,并打通各行业主体,融合信息

检索、社交、金融等综合性跨境数据服务贸易类型,实现了国际贸易中商流、信息流、物流、资金流等的“多流合一”,形成联动交互数字经济生态,推动数据价值的共创共享,促进交易效率的提升、交易规则的形成和交易秩序的稳定,形成了与工业经济时期公司这一商事主体完全不同的新型经济组织^[1],成为新型法律主体。

基于平台在数字经济中的基础性作用^[3],数字经济中的国家间竞争越来越多地表现为数字平台间的竞争,其实质就是各国对数据和流量入口的竞争,而数字技术、数据资源、数字市场的全球分布不均进一步异化了各国的监管重心。

以 TikTok 事件^①为例,自 2019 年以来,美国在 WTO 及 USMCA 等其签署的区域贸易协定中一贯坚持电子商务规则应当允许跨境数据自由流动,但随着美国通过其主导签署的多个 RTAs/FTAs 建立了成熟的数据跨境流动生态圈,占据数字市场优势地位、掌握数字规则制定话语权强势力量之后,美国在维持上述区域贸易协定中数据跨境自由流动立场的同时,却忽然于 2023 年声明放弃在 WTO 的跨境数据自由流动主张^②,以便为国会提供调控、监管大型科技公司的空间。并且美国于次年以“国家安全”之名,要求中国数字平台字节跳动剥离对旗下短视频应用程序 TikTok 的控制权来避免在美遭到封禁,禁止 TikTok 平台在美国收集的数据被跨境传输至位于中国的母公司字节跳动,阻碍通过 TikTok 这一数字平台实现的跨境支付、交易撮合等国际服务贸易的展开以及基于数据分析的广告投放等贸易相关功能发挥。如此一来,美国就可以规避 WTO 中“最惠国待遇”这一基石性条款,对盟友国家基于区域安全维持数据跨境自由流动等便利贸易条件,而对中国等威胁其贸易利益的“对手国家”加强数据出境监管,设置贸易壁垒。

美国的这一做法体现了其背后基于“修昔底德陷阱”^③的深层利益考量。中国拥有数量和市值仅次于美国的跨国数字平台,跨境电商贸易伙伴遍布全球,给美国的数字霸权地位带来冲击。TikTok 案中美国对字节跳动等中国数字平台企

业的打击,也是对 TikTok 平台上的数据分析等具有引流功能的算法技术的争夺^[2],其背后的深层考量是维持本国对数据流量入口的控制,防止数据优势代表的数字经济利益随数据流量被传导至中国等对手国家,危及其在数字经济全球竞争中的霸权地位。所以,为了维护本国数字贸易利益,美国需要规避 WTO 非歧视原则的约束,沿着目前“小院高墙”的思路进一步推进其主导的、以排斥特定国家和产业主体为特征的数字贸易规则体系,进而构建孤立特定国家的数字贸易生态圈。同时,通过区域安排建立有利于本国利益的数字贸易规则范本并影响习惯国际法的形成,实现本国数字贸易利益的最大化。这很大程度上影响了中国数字平台在全球范围内竞争力的提升,同时也造成了中国技术更新与迭代推迟。

(二) WTO 框架下数字贸易规制的现实困境

作为制定国际贸易规则的主要平台,WTO 现有的组织架构、实体规则、决策机制、争端解决机制设置等,对数字贸易的有效规制存在以下困难。

1. 传统规则与数字规则统合难

在具体规则上,WTO 规则体系无法涵盖数字贸易的全部场景。数字贸易打破了传统的货物与服务二分法则,在跨境数据流动驱动的数字贸易

① 美国众议院在 2024 年 3 月通过《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法案》规定,年活跃用户超过 100 万的社交媒体软件如果不通过出售股份等方式切断与“受外国对手控制实体”的联系,将不得不从应用商店下架,否则将可能被总统认定为受到“外国对手的控制”,并构成“国家安全风险”。TikTok 上诉后,美国联邦最高法院于 2025 年 1 月 17 日作出最终裁决,以 9:0 的结果驳回 TikTok 的上诉,裁定该法案符合宪法。TikTok 于次日晚关停了对美用户服务。尽管美国总统特朗普已签署行政令,要求该法案未来 75 天内暂不执行,但该法案未来的走向仍有较大不确定性。

② WTO 网站,https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/joint_statement_e.htm,2024 年 10 月 5 日访问。

③ “修昔底德陷阱”起源于古希腊历史学家修昔底德总结雅典和斯巴达冲突的根源的相关论述,21 世纪以来常被引用分析中美关系,意为一个新崛起的大国必然对当前大国产生威胁,当前大国基于该威胁也会有所回应,战争随之产生。

过程中商品贸易和服务贸易难以区分开^[14]。例如,通过跨境电商平台购买实物商品,这个过程还包含营销、跨境支付结算、跨境物流等一系列服务,很难将其与商品贸易和服务贸易区分开。这种颠覆性变革需要重新调整 WTO 项下的服务分类(W/120)^[15],甚至需要增设以数字经济为前提的新服务分类,以涵盖数字出版、数字音乐、数字电视、数字电影、软件和信息服务等数字贸易商品和服务新类型。基于该原因,在 WTO 数字贸易、电子商务谈判中,至今未能明确数字贸易的定义。除此之外,数据的价值、地域管辖、定价和权属等基础制度缺失也导致数字贸易具体规则在 WTO 规则中的嵌入存在极大的难度。

2. 不同经济体共识形成陷入僵局

WTO 采用“共识”(亦常被称作“协商一致”)的决策模式,并辅以投票表决^①。共识机制是一种维持现状的决策模式,共识程序设计的精妙之处在于打破共识需要明确表示反对,成员国在表决时缺席、弃权或者沉默均无法阻碍共识的形成。

在 WTO 电子商务新议题的谈判中,不同数字经济发展阶段的成员国的关注议题和规则谈判能力差异明显,利益诉求分歧巨大,共识机制经常存在被滥用的风险并成为规则难产的根源^[16],导致了 WTO 决策过程繁琐和效率低下,造成“多哈回合”谈判进入僵局,WTO 的谈判功能受到空前质疑^[17]。

基于国际经济开放的马太效应,国力优势程度高的大国不仅在国际经贸规则的形成过程中起主导作用,对现行经贸秩序的破坏力也十分明显^[18]。在 WTO 为传统的国际经贸体系中,以美国为核心经济实力较强的欧盟、日本、加拿大等贸易实体在 WTO 乌拉圭回合谈判中发挥了主导性作用。但中国等新兴经济体的快速发展对传统的国际贸易力量对比产生了冲击,美欧等传统经济大国在经贸规则谈判上的强势地位和话语权被削弱,而大量发展中国家本国数字技术发展尚未达到相当程度,因此对于很多议题意见不大,并不愿明确表示反对^[19]。在随后的包含数字贸易规则的多哈回合谈判过程中各方共识更难达成。

• 90 •

3. 争端解决机制功能发挥受限

不同于共识机制,WTO 争端解决机制创新性地采取逆向协商一致程序,经争端一方提起,争端解决机构受理后由专家组审理,除非全体一致决定否决专家组和上诉机构的争端解决报告,该报告即自动通过,实质上等同于确立 WTO 争端解决机构的“强制管辖权”^②。这一重大突破是 WTO 奠定国际经贸规则建构主要国际组织地位的重要保障,限制了成员国援引国家主权理论对 WTO 规则的违反,使得 WTO 框架下建立的贸易规则更加具有法律上的确定性。然而,在上诉程序中,由于上诉机构的法官任命需要经过协商一致,自 2017 年起,美国滥用成员国权利,通过反对法官任命的方式阻挠上诉机构法官遴选和连任,最终导致 2019 年底上诉机构因成员不足而停止受理案件^[20]。所以,目前 WTO 争端解决机构因美国的蓄意破坏已经无法正常运行。另外,从本质上说,争端解决机构的主要功能在于解决各国间对规则解释或者适用的争端,而前提是成员国已经对争端议题形成共识并生成明确的规则,在 WTO 框架中尚未形成具体的数字贸易国际规则的情况下,单纯依靠争端解决机制无法起到推动新规则构建的作用^[21]。

(三) WTO 传统国际贸易规制逻辑的解构

基于 WTO 规则体系的现行国际贸易秩序形成于工业经济时期,当时国际贸易的对象是各国国内生产的有形货物商品,贸易手段为国内生产后获得他国市场准入进而实现国际销售的模式。工业革命之前,国家主义的兴起加速了重商主义成为国际贸易领域的主要指导原则,各国大多把金银等贵金属作为国家财富的储备方式。因此,关税、配额等“边界措施”成为一国在国际贸易中

① 《WTO 协定》第 9 条第 1 款规定“世界贸易组织应当实行 GATT1947 所遵循的协商一致的决策方式,除非另有规定,若无法协商一致作出决定,争论事项应通过投票表决。”

② 《关于争端解决规则与程序的谅解书》第 6 条第 1 款规定:经起诉方请求,至迟在该请求第一次列入争端解决小组会议议程的下次会议上设立专家组,除非在该争端解决小组会议上全体一致决定不设立专家组。

保护本国利益的最有效手段。各国通过边界措施提高进口商品价格,获得“贸易条件外部性”,向他国转嫁成本,从而达到奖励出口、限制进口、增加本国财富盈余的目的,但这实际上这是一种“以邻为壑”的贸易保护主义行为,并易使相关国家陷入“囚徒困境”^[2]。

18世纪中后期,工业革命中大规模的机器应用迅速成为占主导地位的生产方式,技术要素和资本要素取代旧时代的土地要素和劳动力要素成为核心生产要素。重商主义政策开始受到质疑,并有观点主张贸易自由也能增加国家财富^①。19世纪初,李嘉图进一步创立了“比较优势”学说^②,成为贸易自由化的理论基础。第二次世界大战后,自由贸易开始得到部分国家的实践,通过GATT的多年积淀于20世纪90年代建立了WTO框架下的多边贸易体制,围绕市场准入,建立最惠国待遇,建立了一种以“互惠”为基础、以关税减让为手段、以贸易自由化为目标的国际贸易准则,通过关税协调各国限制货物进出口、服务市场准入的尺度,以统一的国际标准排除或限制各国政府对国际贸易的不当干预,维持国际贸易的公平性,这符合各国追求自由贸易的贸易利益需求。WTO框架下基于“互惠”“非歧视”原则,围绕市场准入建立的贸易规则固定了商品的国际相对价格水平,稳定了其在各国的相对市场份额,并在全体成员国之间建立了非歧视性的低关税水平,事实上对上述贸易外部性起到了抑制作用,促使各国政府在确定关税税率时能够兼顾更加广泛的利益考量并在价格上进行妥协,最终实现相对公平、能尽可能兼顾各方利益的关税方案,提高了经济效率,促进了贸易自由化发展^[23]。

因此,WTO框架下数字贸易规则谈判长期陷入僵局的原因在于,WTO是工业经济时代的产物,是顺应工业经济时代资本、技术等生产要素驱动的生产力发展所产生的生产关系,在此基础上,其规制的底层逻辑是围绕关税实现的基于“权利”形成公正价格调整各国贸易利益,从而促进贸易自由的范式。而在数字经济时代,数据成为新的生产要素驱动新质生产力发展,产生了平台、数据、算法这一套新的国际法律主体、客体和行

为,需要一套完全不同于工业经济时代规制逻辑的、顺应数字经济规律的国际数字规则为WTO数字贸易新规则的生成提供基础制度支撑。

二、创设WDO的理论证成

(一)“平台、数据、算法”三维结构

随着数字经济的壮大,具备数字化能力的数字平台将成为产业出海的重要基础设施,而用户是以自身的数据价值以及使用时间的流量价值(注意力)向平台进行了有偿给付。在数字经济时代,数字平台本质上是一个汇聚海量实时动态数据的数据集合,大数据、人工智能、区块链等颠覆式技术集群支撑的算法激发了数据要素的市场价值,驱动了平台、数据、算法三维结构(P-D-A Paradigm: Three-Dimensional Structure,以下简称“PDA范式”,如图1)的市场交易新格局,从而对基于工业经济形成的现行国际贸易秩序带来巨大的挑战^[2]。

根据平台、数据、算法三维结构,平台在数字经济中处于基础组织地位,用户向平台贡献的其本身的数据价值及其注意力停留在平台上带来的流量价值是平台的核心竞争力量,算法等技术通过为数据赋能实现平台在市场竞争中力量的强化^[24]。以WTO为主的传统国际经贸规则通过基于互惠原则的“关税减让”调节各国的市场准入,实现“非歧视”的公平贸易;工业经济时代关注静态的权利,通过赋权保护利益,而在数字经济时代,动态的行为更加重要,基于平台、数据、算法三维结构,对主体的行为施加限制或设置规范对于保护利益更具实际作用^[2]。

数据具有价值创造属性,对数字贸易的规制需符合其特性,最大化激励数据价值创造。具体来说,需要结合数字平台这一新的数字经济法律主体的流量入口特征、数据这一新的法律客体的

① 英国经济学家亚当·斯密在《国富论》中提到:“外国若能供给比我们制造者更廉价的货品,最好是购买他们的,作为我们自己行业生产的一部分。”

② 李嘉图在《政治经济原理》一书中,举例论证了在国际贸易中,一国可找出自己的优势最大或者比较劣势最小的产品进行生产与出口;而进口自己不具优势或者劣势最大的产品。

价值创造属性,通过建构新的安全保障模式和利益分配范式对各国监管施加外部限制,保障正常商贸往来中的数据跨境自由流动,在平台、数据、算法三元融合格局下对数字经济时代的国际贸易规制逻辑进行重构,如此才能消除各国监管冲突造成的数字壁垒,畅通数字经贸往来,促进数字经济全球化健康发展。

(二) WDO 数字贸易规制逻辑的重塑

传统国际贸易规则从根本上说产生于工业经济和资本主义发展的需要^[25]。按照市场经济的逻辑,资本主义的发展是通过先确权、再定价交易,从而形成市场。而在数字经济时代,支撑新质生产力发展的数据要素是数字经济发展的新动能,比定价交易更重要的是数据价值创造和共享机制,比市场机制更重要的是生态机制。数据的战略资源优势可以直接转化为竞争优势,数据取代价格成为重要的大国竞争和博弈的工具。当然,市场机制仍将长期存在,但是应当大力发展可以弥补市场经济缺陷和不足的生态机制。新质生产力的创新,既包括技术和业态模式层面的创新,也包括管理和制度层面的创新^①。以数据要素为核心的新质生产力发展,需要构建一套围绕数据生产、流通、交换和消费全过程的新型生产关系。

与土地、资本、劳动力等传统生产要素相比,数据要素“可用不可见”等新利用方式将经济业态从“控制权转移”向“利用”转变^[26]。大多传统要素在一定时间仅能投入唯一用途,为了“物尽其用”需要使有能力的主体独断决策,以提高利用效率和产出效用。而数据要素的非稀缺性等特征需要开放式的多主体利用,避免单一主体营造“围墙花园”。故各国数据本地化存储等数据出境限制性措施实际上是建造了更大的“围墙花园”。因此,需要结合数据性质重构新治理模式,实现价值倍增,激活经济新动能。

基于数据要素的特征,数字贸易规则谈判过程中主要存在以下痛点:一是数据的无形性等特征决定了其无法像有形商品一样在跨越各国疆界时通过海关手续予以限制,因此无法用 WTO 框架下的关税手段去衡量或协调数据跨境流动中的

监管冲突;二是数据的价值生成逻辑决定了数据价值因流动增加而非消耗,数据的采集、利用、储存、交易等每一个环节的参与者都因付出了数字劳动而对数据增值作出贡献,数字技术强国依据技术优势、市场优势等掌握了数字国际规则制定的话语权,来自发展中国家的数字劳动并未获得合理对价,与数字强国的贸易地位不平等。

数据要素价值共同创造的特征有助于形成促进经济主体社会化合作以及共享利用生产要素的新法律规则,建构动态多元赋权机制,以此重塑更加强调开放合作共赢的国际贸易往来状态,建构全球共建共治共享的贸易秩序架构。

近年来,WTO 电子商务/数字贸易议题谈判陷入僵局,始终未能取得明显的实质性进展的根本原因就在于 WTO 规制的底层逻辑来自工业经济时代。在数字时代网络空间的贸易活动蓬勃发展的同时,物理空间中的传统国际贸易活动依然是人类生产、生活、经济交往的重要方面,WTO 目前的框架规则对于当前的国际贸易中的传统部分依然适用,不可或缺;但上述规则又无法直接适用于网络空间,要解决网络空间中数字贸易规制的需要,就要构建一个完全不同于物理空间以关税为主要手段的规则架构,构建以“收益分配”激励价值创造逻辑的新的规制范式,而两种规制模式之间的巨大差异导致 WTO 改革中目前的“旧瓶装新酒”模式完全无法在各国间达成共识,无法形成有利于数字经济健康发展的国际贸易规则。从长远来看,数字领域的国际规则最终还是需要单独建构一个基于数字经济规律、解决数字规则建构痛点、实现各方数据利益公平分配的法律框架,因此,最终还是需要有一个全新的世界数据组织 (World Data Organisation) 来统合确定数字经济时代新的法律主体、客体之间的权利义务边界,避免在传统框架下建构数字规则的“水土不服”而带来的高昂的转化成本,从而使数字贸易规制从

① 参见《习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调:加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展》, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202405/content_6954761.htm。

WTO 电子商务谈判的僵局中解放出来。

三、WDO 的建构路径

(一) WDO 的目标与宗旨、类型与功能

1. 新的目标: 价值创造

与土地、资本、劳动力等传统生产要素相比,数据要素“可用不可见”等新利用方式将经济业态从“控制权转移”向“利用”转变^[24]。数据要素价值共同创造的特征有助于形成促进经济主体社会化合作以及共享利用生产要素的新法律规则,建构动态多元赋权机制,以此重塑更加强调开放合作共享的国际贸易往来状态,建构全球共建共治共享的经贸秩序架构。

在数字贸易中,数据不同于传统的有形货物、知识产权等交易对象,对数字贸易的规制主要基于货物的可消耗性、非共享性,建立以“控制”为核心架构的规则体系,即追求“我控制”。因此,传统 WTO 框架下以关税为规制手段,通过货物通关时的关税高低实现不同货物在全球各国间的流动;但数字贸易是由数据支撑的,数据的可复制性、零边际成本的特征决定了数据本身及其支撑的数据产品的跨境交易不同于传统货物的跨境流动,对数据及数据产品的跨境流动的国际规制目标不同于传统的“控制”,而更应关注“利用”。无论数据通过流动实际被几方“控制”,各方真正关注的实际是数据价值能否得到有效发挥,进而让参与方获益。因此,明确激发数据价值创造的目标与宗旨,是符合实践需求的数字贸易规则生成的前提。

2. WDO 的类型

目前国际上的各种国际组织千差万别,宗旨任务、组织形态和活动程序都具有较大差异。

第一,按照国际组织的基本性质与职能范围来看,所有的国际组织可以划分为综合性国际组织与专门性国际组织两大类。综合性国际组织是以某个领域为核心,同时也涉及其他多领域的国际组织。例如联合国,其主要职能是维护国际和平与安全,但其下设的经济及社会理事会也就经济、社会和环境问题进行协调、政策审查和政策对话并提出建议。而专门性国际组织针对专业领

域的职能,是以某一专门技术活动为任务的组织,如 WTO 是以国际贸易协调为主要职能的组织,国际海事组织专注于海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的职能。目前,对数据跨境流动等相关问题的国际规制的争论主要存在于国际贸易领域,这是因为数字经济发展需求与工业经济传统法律框架的矛盾最先在贸易领域得以显现和激化,国际贸易领域对数据跨境流动规则的需求也最为激烈。不得不承认的是,不仅贸易领域,在国家安全等综合领域也涉及数据问题,例如一国针对他国数字基础设施进行的网络攻击等行为也涉及传统国际法中国家责任理论在网络空间中的适用问题。因此,WDO 的职能范围未来将不仅仅局限于贸易领域,也可能涉及国际和平与安全等综合领域,WDO 的类型建构应定位于综合性国际组织。

第二,按照组织成员是否向国际社会成员开放、地域性特点,国际组织还可分别被分为全球性组织和地域性组织以及开放性组织和封闭性组织,从数字经济全球化的特点和数字贸易开放性的要求来看,WDO 应属全球性开放性组织。

因此,WDO 的建构方向应当是一个开放性的、全球性的综合国际组织。

3. WDO 的功能定位

国际组织的权力基于各成员国的授权,最终是为成员国所规定的共同目的服务^{[27] 150}。而不同的国际组织基于特定的任务需承担不同范围和不同程度的权利与义务。因此,只有明确 WDO 的功能与定位才能明确具体规则与组织模式的建构方式。

WDO 是各国为解决网络空间中的国际法适用问题而建立的,其主要功能在于弥补工业经济时代适用于物理空间的传统国际法律框架无法解决数字经济时代网络空间中出现的新的法律冲突而存在。具体需要解决的问题包括:一是数据基础制度的统一问题;二是各国监管法规的协调与监管合作的促进问题;三是传统国际法在网络空间的适用,也就是网络空间的国际治理问题;四是数字新规则的建构问题等。

因此,WDO 的构建路径、成员资格、组织机

构、职能范围、决策程序、争端解决机制等都应当结合上述功能定位予以确立。

(二) 基于世界互联网大会的构建方式

关于国际组织的构建方式,国际上并无统一范式,目前主要有以下三种类型。

一是国际条约或者国际协定路径。例如 WTO 就是在国际协定 GATT 的基础上发展而来的,后经《马拉喀什协定》于 1994 年正式建立;联合国是 1945 年第二次世界大战接近尾声时,50 个国家的代表在美国旧金山举行了联合国国际组织会议,起草并签署了《联合国宪章》,从而联合国得以建立。

数字贸易谈判过程的最大痛点在于,各国复杂的利益冲突使得在具体规则生成上难以达成各方均能接受的共识,而 WDO 的构建如果以先建立国际条约或者国际协定的路径开始,极易产生和目前数字贸易规则碎片化现状同样的规则生成困境。具体来说,在各国基于本国利益考量不愿意与采用不同数据保护与监管标准的国家就数据监管进行国际合作或建立数据跨境流动机制和数字贸易生态圈的情况下,各方很难共同签署一个涵盖不同数据监管法律传统的国际条约或者国际协定,最终还是会形成不同国家团体的区域性条约或者协定,形成各自为政、条块分布的格局,无法解决数字贸易规则碎片化的根本问题,无法成为全球性国际组织的建构基础。因此,WDO 不宜采用国际条约或者国际协定的方式建立。

二是附属国际组织的路径。例如世界卫生组织的构建过程就是,巴西和中国代表 1945 年在联合国成立大会上提议建立一个全球性卫生组织,接着即召开会议制定其章程。联合国经济及社会理事会指示秘书长于次年组织相关会议,起草并通过了《世界卫生组织组织法》,1946 年 7 月 22 日由 51 个联合国会员国和其他 10 个国家的代表签署,随后世界卫生组织正式成立,成为联合国系统内国际卫生问题的指导和协调机构。

在数字贸易规则碎片化背景下,亟待生成的是全球性的国际规则,以协调数字技术强国与新兴国家之间的数字贸易阵营化冲突。如果 WDO 以附属国际组织的路径建立,需要附属全球性国际组织才有可能建立全球性的数字贸易规则。目

前比较合适的国际组织包括联合国和 WTO。如果将 WDO 作为 WTO 的附属国际组织建立,其所要解决的问题与前述 WTO 改革的困境是一致的。此外,WTO 的规则较为特殊,本质上是一个一揽子协定,是由一系列国际协定规则组成的,按照《马拉喀什协定》的规定,WTO 本身并不具有建立附属国际组织的职能。而联合国平台是目前成员国涵盖范围最广的国际组织,对于扩大 WDO 规则的影响范围具有积极的作用,但是结合其已有的附属国际组织的运行来看,这些附属国际组织的地位对于 WDO 功能的发挥有一定的限制性影响。联合国的主要附属国际组织包括联合国粮食及农业组织、国际民用航空组织、国际农业发展基金、国际劳工组织、国际海事组织、国际电信联盟等,这些国际组织大多专注于特定领域的行业标准设置、促进各国技术合作以及学术交流等方面的综合事务,并没有权限制定实体的国际规则,这与 WDO 制定数字贸易国际规则的初衷不相符,因而该路径也不适合 WDO 的建构。

三是区域性组织全球化的路径。区域性国际组织的全球化一般在一些实践亟需的领域出现,体现了国际社会面对新的国际议题的共同利益。例如,IMF 成立于 1944 年的布雷顿森林会议,其最初的目的是在二战后重建国际货币体系,促进国际货币合作,确保汇率稳定,并提供短期资金支持以帮助国家解决国际收支问题。最初的成员主要是二战后经济重建的国家。但随着更多国家的加入,IMF 的成员国数量逐步增加,组织的影响力也逐渐扩大。20 世纪五六十年代,许多新独立的国家加入 IMF,这些国家主要来自非洲、亚洲和中东地区,这使得 IMF 的覆盖范围更加全球化,IMF 也开始在全球经济政策中扮演更为重要的角色。目前,IMF 已成为具有全球影响力的国际组织,致力于促进国际货币合作、确保金融稳定、促进高就业和可持续经济增长。IMF 从一个关注特定区域和经济重建的组织,发展到现在已经拥有 190 多个成员国,它在全球经济监测、政策建议、金融援助和能力建设等方面扮演着重要角色,是全球性的国际经济治理机构。OECD 其前身是欧洲经济合作组织(OEEC),主要关注欧洲国家的经济合

作与复苏。1961年,OECE转型为OECD,组织目标从欧洲经济复苏扩展到更广泛的经济合作与发展。OECD的成立标志着其开始关注全球经济问题,并吸纳了美国和加拿大等非欧洲国家和日本、澳大利亚、新西兰等亚太国家加入。随着这些国家的加入,OECD的影响力逐渐超越欧洲,开始在全球经济政策中发挥更大作用。20世纪90年代,OECD继续扩大其成员,接纳了韩国、智利、以色列和爱沙尼亚等国家,并与中国、印度、巴西、印度尼西亚和南非等主要新兴经济体建立更紧密的联系。这一过程使OECD从一个专注于欧洲经济合作的组织,发展成为一个在全球经济政策中具有重要影响力的国际组织,推动了全球经济的可持续发展和合作。

从数字贸易全球规制的角度来看,这条路径比较符合建构WDO的实际。一方面,基于已经建成的国际组织制定数字规则,可以避免目前陷入僵局的国际协定和国际条约谈判导致的规则碎片化问题;另一方面,一个独立的全球性国际组织在规则影响力和制定国际规则的法定权利方面都更优于区域性国际组织和附属性国际组织,更有利于规则形成后的国际影响力的提升。更重要的是,相较于国际条约或协定路径的从无到有,区域性国际组织的国际化路径实现的是从有到优、做大做强,实践中更具有可操作性。

因此,在已有的区域性国际组织的基础上,通过谈判制定新的规则并开放更多的成员方加入,是建构WDO的更优方案。

(三) WDO的成员资格、组织机构与规章制度

1. 成员资格

国际组织的成员是国际组织的主体。数字贸易规则的制定属于互联网治理范畴,传统上,一般只有完全的政府间国际组织才具有制定各领域国际规则的权限。例如WTO的成员以国家为主,还有少量关税区,均为政府成员。但基于网络空间的虚拟特性,单靠政府自身无法承担国际互联网治理的责任^[28]⁴⁸,还需要包括企业、私营机构、公众等在内的多方主体的相互协作,因此,WDO应采取更加灵活、务实的态度,根据具体的问题和议题确定符合数字经济规律的治理模式。

数字经济时代,数据治理国际规则的建构主要属于网络空间国际规则的制定范畴,且尚属于各国试图建章立制的早期阶段。目前主要存在美欧等发达国家主导的“多利益攸关方”^①和中国等发展中国家倡导的“国家主权”模式两种机制分歧。当前,美国主导的“多利益攸关方”模式得到国际社会的一些认同,但“多利益攸关方”模式限制政府在网络空间国际治理中的主导作用,主张应由私营部门和公众加入与政府共同治理。美国倡导“多利益攸关方”模式的深层原因在于私营部门和公众这两类主体的历史传统和治理经验在美国等西方国家中相对于发展中国家具有压倒性优势,让上述非国家行为体参与治理有利于美国等发达国家既有优势的扩大^[29]。因此,在“多利益攸关方”模式下,发展中国家始终处于弱国际话语权的边缘地位,这不仅仅是美国关于数字国际规则话语权的争夺布局,也是美国试图凭借其长久以来的技术优势和在国际规则制定中的强话语权维护其在数字贸易中的绝对优势的战略布局。

与美国相反,中国、俄罗斯等国家主导的“国家主权”模式强调网络主权的重要性,主张应由政府主导对互联网安全的治理,希冀打破发达国家在网络空间国际规则制定中的绝对主导地位,从而增强话语权。这种立场主要基于这些国家在技术标准的制定和国际规则制定方面存在技术水平不高、法律传统较弱等情况,且国家的私营部门等非国家行为体参与数据安全治理的经验十分有限,甚至正处于无序扩张或有限发展的阶段,在与发达国家的竞争过程中无法有效维护本国利益。主权原则是国际法的基本原则,从这一基本原则出发,着眼于联合国等传统政府间组织国际平台参与数据治理国际机制的构建,更有利于增强与

^① “多利益攸关方”模式最早在2001年世界信息社会峰会上提出,主要由政府、私营部门和公民三大主体来进行网络空间的治理,联合国大会2002年的决议对该模式予以了认可。United Nations General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on the report of the Second Committee (A/56/558/Add.3) I, Jan 31 2002, Fifty—sixth session A/REs/56/183.

发达国家博弈中的软实力,从而有效应对技术强国的网络霸权主义行为。

基于不同利益考量的上述两种治理机制具有极强的对立性,难以有效协调,进而导致国际数字规则构建进展十分缓慢。例如,在2012年国际电信联盟就《国际电信规则》进行重新审定过程中,因发展中国家和发达国家存在观点上的分歧,致使签署了新规则的发展中国家成员国和拒绝签署新规则的发达国家成员国各自按照不同的新旧规则履行国家义务,由此新规则的制定失去了应有的效果。但同时,双方也并非对另一种模式全盘否定。例如,美国虽然多年来均倡导“多利益攸关方”模式,但实际上美国也积极参与WTO的电子商务、数字贸易谈判并主导多个区域性贸易协定等纯政府主导的国际规则制定谈判活动。

从数字贸易所处的产业现状来看,数字贸易是数字经济的产物,广泛存在于数字经济的各场景中。基于“平台、数据、算法三维结构”,数字贸易基本是通过大型数字平台实现的,大型数字平台在运营过程中具有收集数据的流量入口优势,具有先进的算法等技术支撑,加之当前这些大型数字平台跨国运营的经营模式,使得频繁地海量数据跨境流动得以实现。因此,代表平台的从事网络运营、社交媒体、金融支付等行业的互联网科技企业成为数字贸易中的最重要主体,这些企业主体的参与对于数字贸易规则的建立起到极大的支撑作用。

尽管数字平台企业等非国家主体的参与对于数字贸易规则谈判具有非常积极的助推功能,但这并不代表“多利益攸关方”模式所主导的限制政府权力、放大企业和个人权力的方案适合数字贸易规制。虽然可以在谈判过程中引入数字平台企业在产业实践和行业标准方面的经验,确保谈判结果能够符合产业实践,但鉴于数字贸易所牵涉的国家安全、隐私保护的风险,以及“数字鸿沟”和规则碎片化背景下美国等数字技术强国借此实施数据霸权,WDO中的数字贸易规则谈判还是应以尊重各国在网络空间中的主权为前提,可在尊重各国主权基础上适当引入数字平台企业及其他私营机构、科技组织等作为咨询专家、技术支

撑等,辅助成员国间的数字贸易规则谈判。

2. 组织机构

一是决策机关:全体会议。在WDO内设置一个全体会议机关,由所有成员方派代表参加,每年开会一次,主要职能是制定WDO的方针政策,审查预算,接纳新成员,选举行政首长、执行机关成员并审议相关报告,制定及修订有关规章,就相关事项提出建议等。

二是执行机关:理事会。理事会的职能是执行全体会议的決定,处理WDO管辖范围内的事项,提出建议、计划和工作方案并负责实施。全体会议休会期间,由理事会行使其职权。理事会由24名执行董事组成,其中8名由各方商定的8个成员方分别委派,其余16名由其他成员国按地域分成选区联合推选产生。

三是秘书机关:国际秘书处。国际秘书处作为WDO的秘书机关,是WDO行政管理工作的核心;设秘书长一名,秘书处的办事人员从各成员国挑选产生,秘书长和秘书处主要负责处理WDO的各项日常工作,协调组织中各常设机关的活动,并为其提供各种服务,具有财政、会务、调研、技术、情报等多方面职能。

3. 规章制度

一是会议制度。鉴于面对数字领域新议题,规则需求较高,WDO应设置经常会议、定期会议和特别会议三种形式。经常会议不定时,可随时召开;全体会议要求每年举行一次,理事会每年举行三次。此外,对于特殊情况,可以在定期会议之外经过报备程序举行特别会议来处理。

二是表决程序。WTO数字议题谈判陷入僵局,表明其采用的“协商一致”表决方式无法有效协调各成员方的立场差异,进而导致无法在WTO框架下经过该表决程序形成具体的数字贸易规则。基于该经验,WDO表决程序的设置应更多考虑当前数字经济领域各国的利益冲突与法律传统。在投票权的分配方面,考虑到目前大多数发展中国家由于数字基础设施不健全、数字技术能力较弱,不具备参与数字规则制定并提出有利于数字经济发展实践的具体方案的客观实力,表决权分配时要注意既不能剥夺或削弱发展中国家的

投票权,又不能使其基于数量优势影响 WDO 作出科学决策。建议采取加权投票制与一国一票制相结合的分配方式,在一国一票的基础上,依据各国数据基础设施建设、数字技术能力、对发展中国家数字基础设施援助程度、在数据价值创造中的贡献程度增加相关国家不同比例的投票权。在表决权的集中问题上,吸取 WTO 协商一致通过表决程序导致谈判僵局的教训,采用多数通过制,三分之二以上的票数通过即可作出决策。

三是争端解决机制。鉴于目前数字贸易争端主要存在于跨国公司经营的商事活动中,可以探索建立专门的仲裁机关,通过个案的裁判为统一规则的形成贡献实践案例。但结合 WTO 上诉机构因美国阻挠而停摆的经验,针对个案争端解决机构作出的裁决的遵守要以 WDO 的稳定运行为前提。

五、结语

数字经济时代的生产生活方式创造了全新的法律关系,也对传统国际组织规则体制带来了巨大冲击。数据作为生产要素,与传统的技术、资本等生产要素存在本质区别。这种区别决定了传统国际组织的规制逻辑无法完全满足数字时代的新需求。需要注意的是,数字经济并非对实体经济的替代,而是进一步丰富了人类的生产生活方式。大部分传统的商业模式、生活方式仍然长期存在。因此,本文提出创设 WDO 以应对数字经济挑战的设想,并不意味着抛弃旧的规则框架,而是在构建符合现实需要的新规则体系的同时,与传统规则体系交汇融合,更好地服务人类的生产生活需求。以数字贸易这一专门领域为例,WDO 的功能在于通过构建基础的国际数字规则为 WTO 数字贸易规则谈判提供基础制度支撑,帮助 WTO 走出目前各成员国因在数据跨境流动、数据安全、数据权属、数据产品定价等基础制度方面的立场存在法律冲突而阻碍共识形成的谈判僵局,而非替代 WTO 本身。因此,中国作为世界上最大的发展中国家,除了坚持 WTO 在国际贸易规则谈判中的核心地位,积极参与 WTO 各项议题谈判并积极对接高标准经贸规则之外,可倡导并主导创

设 WDO 作为数字贸易全球治理的方案之一,为全球提供公共产品,增强我国在数字国际规则制定中的话语权,为数字贸易全球治理贡献“中国智慧”。

参考文献:

- [1] 刘金瑞《迈向数据跨境流动的全球规制:基本关切与中国方案》,《行政法学研究》2022 年第 4 期。
- [2] 孙南翔《跨境数据流动规制的模式差异、协调路径与中国方案》,《法治社会》2024 年第 3 期。
- [3] 刘敬东《全球经贸关系演变中的国际法治危机及其应对》,《中国法学》2023 年第 3 期。
- [4] Sorgho Z, “RTAs’ Proliferation and Trade-diversion Effects: Evidence of the ‘Spaghetti Bowl’ Phenomenon”, *The World Economy*, vol.39, no.2, 2016.
- [5] 杨东、乐乐《元宇宙数字资产的刑法保护》,《国家检察官学院学报》2022 年第 6 期。
- [6] 凌晨、秦思佳、戴翔《数字化转型、全球价值链嵌入与制造业企业 TFP》,《国际商务研究》2024 年第 5 期。
- [7] López González, J. and M. Jouanjean, “Digital Trade: Developing a Framework for Analysis”, *OECD Trade Policy Papers*, no. 205, OECD Publishing, Paris, 2017.
- [8] 张新宝《论作为新型财产权的数据财产权》,《中国社会科学》2023 年第 4 期。
- [9] 杨东《论反垄断法的重构:应对数字经济的挑战》,《中国法学》2020 年第 3 期。
- [10] 吴汉东《数据财产赋权:从数据专有权到数据使用权》,《法商研究》2024 年第 3 期。
- [11] 熊丙万、何娟《论数据要素市场的基础制度体系》,《学术月刊》2024 年第 1 期。
- [12] 杨东、郑清洋《从 TikTok 事件看数字人民币的路径选择:从流量入口到金融优势的转化》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版) 2021 年第 4 期。
- [13] 杨东、黄尹旭《元平台:数字经济反垄断法新论》,《中国人民大学学报》2022 年第 2 期。
- [14] 刘佳奥《WTO 规则下数字产品的法律属性研究》,《国际法学刊》2022 年第 1 期。
- [15] 李晓玲《WTO 成员减让表之服务部门的解释方法——基于中国电子支付服务案的研究》,《国际经贸探索》2015 年第 2 期。
- [16] 石静霞《世界贸易组织谈判功能重振中的“联合

- 声明倡议”开放式新诸边模式》，《法商研究》2022 年第 5 期。
- [17] GuanWenwei, “Consensus Yet Not Consented: A Critique of the WTO Decision Making by Consensus”, *Journal of International Economic Law*, no.1, 2014.
- [18] 孙嘉珣 《涉外法治视角下国际经贸规则形成研究》，《法学杂志》2024 年第 2 期。
- [19] 赵维田 《论 GATT/WTO 解决争端机制》，《法学研究》1997 年第 3 期。
- [20] 杨国华 《WTO 上诉机构危机的国际法分析》，《国际法研究》2024 年第 1 期。
- [21] 许多奇 《治理跨境数据流动的贸易规则体系构建》，《行政法学研究》2022 年第 4 期。
- [22] 高疆、盛斌 《国际贸易规则演进的经济：从市场准入到规制融合》，《国际经贸探索》2019 年第 5 期。
- [23] Bagwell, K. and Staiger R. “An Economic Theory of GATT”, *American Economic Review*, no.1, 1999.
- [24] 杨东、李佩徽 《畅通数据开放共享促进共同富裕路径研究》，《法治社会》2022 年第 3 期。
- [25] 杨东、高一乘 《建构中国自主知识体系：数字法学范式》，《法学杂志》2023 年第 2 期。
- [26] 黄尹旭、杨东 《“利益—权利”二元共生“数据要素 x”的价值创造》，《中国社会科学》2024 年第 2 期。
- [27] 梁西 《论国际法与国际组织五讲》，北京：法律出版社 2019 年版。
- [28] 郎平 《网络空间国际治理与博弈》，北京：中国社会科学出版社 2022 年版。
- [29] 黄志雄、应瑶慧 《美国对网络空间国际法的影响及其对中国的启示》，《复旦国际关系评论》第 21 辑 2017 年。

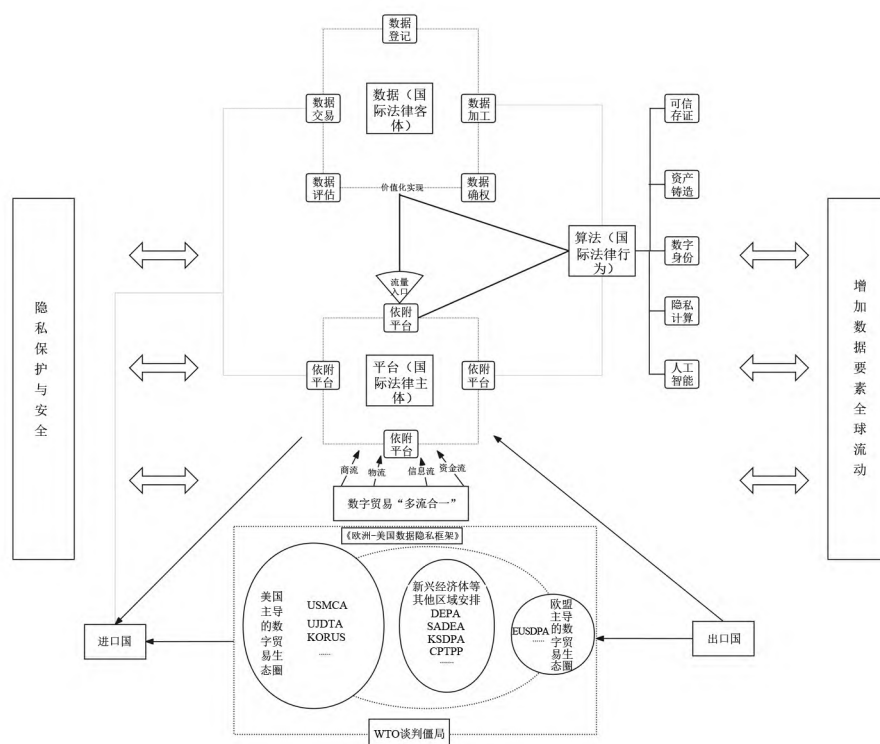


图1 平台、数据、算法三维结构下的数字贸易规则格局

责任编辑：朱 磊